

1500521-36.2022.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... tese, estaria a configurar o delito de tráfico ilícito de drogas, com incidência de uma causa de aumento relativa ao tráfico entre Estados da Federação (art. 33, caput, c.c. o art. 40, V, ambos da Lei nº. 11.343/06).

A ação penal é procedente.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

1ª Vara Criminal

Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500521-36.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500521-36.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2090461/2022 - DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI, 24035465 -

DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI, 2090461 - 02º D.P. BIRIGUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Margareth Campos dos Santos

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

S E N T E N Ç A

Processo nº. 1500521-36.2022.8.26.0603 (Controle nº: 747/2022)

VISTOS.

MARGARETH CAMPOS DOS SANTOS, qualificada nos autos, foi presa em flagrante delito,

denunciada e viu-se processada como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 02 de abril de 2022, por volta das 17h50min, durante o período noturno, na Rodovia SP-300, altura do Km 518, Zona Rural, no Município de comarca de Birigui, entre Estados da Federação, trazia consigo e transportava 2 (dois) tabletes de maconha pesando 1025,47 (um quilo, vinte e cinco gramas e quarenta e sete centigramas), sendo substância entorpecente, que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação prévia de fl. 17.

Oferecida denúncia, a ré foi notificada para apresentar defesa escrita (fl. 80), cuja peça foi juntada às fls. 85/104, sobrevivendo o recebimento da denúncia em 25 de julho de 2022 (fls. 147/148) e a citação da acusada (fl. 163).

Na instrução, foram colhidos os depoimentos de 02 (duas) testemunhas arroladas pela acusação e 01 (uma) testemunha arrolada pela defesa, sobrevivendo, ao final, o interrogatório da ré (fls. 184/185).

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação da acusada, nos termos da denúncia (fls. 217/222).

A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição da ré, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu que a pena seja fixada no mínimo legal; aplicação do disposto no §4º da Lei nº 11.343/06; e o direito de a ré apelar em liberdade (fls. 226/255).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade da denunciada pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico ilícito de drogas, com incidência de uma causa de aumento relativa ao tráfico entre Estados da Federação (art. 33, caput, c.c. o art. 40, V, ambos da Lei nº. 11.343/06).

A ação penal é procedente.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia ficaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido, temos: o auto de prisão em flagrante de fl. 01; a nota de culpa de fl. 05; o boletim de ocorrência de fls. 11/14; o auto de exibição e apreensão de fls. 15/16; o laudo de constatação prévia de fls. 17; o relatório policial de fls. 62/64; os laudos periciais de fls. 116/119, 120/126, 127/130, 134/136 e 191/192; os depoimentos das testemunhas; e a confissão apresentada pela acusada na fase policial e sua posterior retratação em juízo.

Na fase policial, a acusada confessou os fatos, disse que, comprou 01 (um) KG de maconha de um homem com o apelido "Jota", na cidade de Três Lagoas-MS, e estava levando para vender em Goiânia-GO (fl. 04).

Em juízo, a acusada se retratou e passou a dizer que não tinha conhecimento que as drogas estavam naquela bolsa. Relatou que mantinha relacionamento com um homem de nome Márcio, que lhe prometeu um emprego em Goiânia e acabou sendo enganada. Disse que um rapaz de nome "Jota", a pedido de Márcio, entregou a bolsa na rodoviária de Três Lagoas-MS para que a levasse até Goiânia-GO. Afirmou que, durante todo o tempo, o homem lhe telefonava de um número restrito e quando os policiais a abordaram, o homem a ameaçou pelo telefone com os dizendo "Se você citar meu nome, eu sei onde você e sua família mora". Afirmou que estava com medo da ameaça, razão pela qual confessou na delegacia. Em resposta a repregunta, disse que falou o apelido do homem que a ameaçou para os policiais. Não soube dizer o nome completo do namorado nem o endereço para onde estava indo (fls. 184/185).

Como se vê, a ré, na fase policial, confessou a autoria do delito, mas em juízo, negou o crime, na tentativa de afastar a sua responsabilidade penal.

No entanto, a retratação trazida pela ré na fase judicial não afasta a confissão policial, já que está totalmente contrária às provas coligidas nos autos e isolada de todo o conjunto probatório, tendo sido contrariada por provas que apresentaram grau de idoneidade bem mais elevado, não passando de mero expediente utilizado na tentativa de se furtar da responsabilização penal por conduta efetivamente

praticada.

Com efeito, as testemunhas João Vitor Nascimento Lins e Antônio Alexandre de Carvalho, policiais militares, ouvidos em ambas as fases da persecução penal, relataram que abordaram um ônibus da empresa "JK", com itinerário de Campo Grande-MS-Brasília-DF. Em revista aos passageiros e bagagens, na bagagem de mão da acusada foram localizados 02 (dois) tabletes de maconha no fundo falso. Questionada, a ré afirmou que estava transportando de Três Lagoas/MS e até Goiânia/GO (fls. 02, 03 e 184/185).

Os relatos dos policiais evidenciam que a ré incidiu na prática de tráfico ilícito de entorpecentes interestadual.

É cediço que o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Tais depoimentos somente não terão valor quando se evidenciar o interesse dos servidores na investigação penal, e quando suas declarações não encontrarem suporte em outros elementos probatórios idôneos.

A testemunha Suzy de Oliveira Cavalcanti, ouvida em juízo, relatou que é prima da acusada, e que ficou sabendo da prisão dela depois de 40 (quarenta) dias após a prisão. Disse que Margareth saiu de Três Lagoas/MS com destino a Goiânia/GO, para ir atrás de um namorado. Disse que a acusada desapareceu da cidade de Três Lagoas/MS, não dando mais notícias, narrou, que registrou boletim de ocorrência, criou anúncios na internet, divulgou na cidade, devido ao desaparecimento de Margareth. Por fim, disse que Margareth nunca teve envolvimento com tráfico de entorpecentes (fls. 184/185).

No que se refere aos entorpecentes, a perícia apontou que consiste realmente em "maconha" (exame químico-toxicológico de fls. 191/193).

Quanto à caracterização do tráfico de drogas, pouco importa o fato de ter a ré sido contratado por terceiros, porque o artigo 33, caput, da Lei de Drogas, incrimina, dentre várias, a conduta de transportar e trazer consigo a droga para fins de comércio a terceiros, ainda que o entorpecente seja de terceira pessoa.

De outra parte, a grande quantidade de entorpecente apreendido, ou seja, 1.025,47 gramas de maconha, as circunstâncias da abordagem da ré (policiais encontraram o entorpecente no fundo falso da bagagem da ré); a apreensão de aparelho celular e balança; e a confissão da ré na fase policial, estão a caracterizar a traficância. Nunca é demais lembrar que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo ou transporte a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado. Lembrando que a ré foi denunciada por transportar e trazer consigo o entorpecente.

Por fim, a causa de aumento do artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas, também restou demonstrada, quer pela confissão da ré na delegacia, quer pelos depoimentos dos policiais, que confirmaram que a ré transportava o entorpecente do Estado de Mato Grosso do Sul e foi abordada no Estado de São Paulo, inclusive, a própria ré afirmou que a droga saiu de Três Lagoas/MS e estava sendo transportada para Goiânia/GO.

Portanto, referida causa de aumento é aplicada quando restar comprovado que a ré praticou qualquer uma das condutas descritas no caput do artigo 33, também nas situações trazidos pelo artigo 40 da Lei de Drogas, o que foi o caso dos autos.

É óbvio que alguém que transporte mais de um quilo de maconha, tinha a intenção de "pulverizá-la" ou "disseminá-la" em outro Estado. E ainda que a intenção da ré fosse apenas transportar, e não pulverizar ou disseminar a droga, a conduta da ré está tipificada no artigo 33, caput, e 40, inciso V, da Lei de Drogas.

Sendo assim, não resta dúvida de que, no dia, horário e local indicados na denúncia, a acusada transportava e trazia consigo, para fins de colocação ao consumo de terceiras pessoas, 1.025,47 gramas de maconha, substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A conduta da ré encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº. 11.343/06.

Neste ponto, não se pode olvidar que o tipo penal do artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 é chamado de tipo misto alternativo, possuindo vários núcleos, dentre eles transportar e trazer consigo, condutas essas efetivamente praticadas pela acusada, mas que caracterizam crime único.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade da denunciada ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

A acusada, ao que consta dos autos, não ostenta maus antecedentes. Todavia, nesta fase da aplicação da pena, deve ser levado em conta que a introdução, no mercado, da considerável quantidade de droga apreendida (1025,45 gramas de maconha), se fosse alcançada, traria efeitos altamente lesivos à sociedade. Evidente, assim, a necessidade de um maior rigor na fixação da pena-base, em patamar acima do mínimo legal, lembrando que seria absolutamente desprovido de razoabilidade apená-los com a sanção base mínima, tratando-os igualmente, por exemplo, a quem fosse preso traficando algumas gramas daqueles entorpecentes.

Evidente, assim, a necessidade de um maior rigor na fixação da pena-base, em patamar acima do mínimo legal.

Essa é a posição de nossos Tribunais:

“Na avaliação das circunstâncias legais para a fixação da pena, em se tratando de tráfico de entorpecentes, devem influir decisivamente a espécie e a quantidade da droga. O tipo de entorpecente é dado que indica o grau de nocividade para a saúde pública, correlato ao indicador das consequências do crime; a quantidade, quase sempre, aponta para o grau de envolvimento do infrator com o odioso comércio, indicando a medida de sua personalidade perigosa e voltada para a prática criminosa” (STJ, HC 13.231-MS, 5ª T., j. 22.08.2000, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 09.10.2000 – RT 786/599).

“Nos casos de tráfico de entorpecente, a fixação da pena obedecerá aos critérios do art. 59 do CP entre eles os motivos, as circunstância e consequências do crime, razão pela qual se admite a fixação de pena-base acima do mínimo legal, se houve apreensão de grande quantidade de droga” (STJ, HC 11.235-SP, 5ª T., j. 16.03.2000, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 17.04.2000, RT 783/594).

“Admissível, em tema de comércio clandestino de entorpecente, é a maior severidade na repreensão penal em face da natureza mais nociva ou da maior quantidade de substância tóxica apreendida” (TACRIM-SP-AC-Rel. Geraldo Pinheiro – JUTACRIM 44/293).

“A alta nocividade da cocaína está a exigir especial rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, a aplicação aos traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao elevado risco que a nefanda mercancia acarreta à saúde pública” (TJRS – AC – 687055624 – Rel. Alberto de Moraes Lacerda – RJTJRS 130/154)

PENA – Agravantes – Tráfico de entorpecentes – Associação – Hipótese em que, se a Justiça Pública houvesse apelado, caberia modificação no decreto condenatório, pois a grande quantidade de entorpecente apreendida justificaria plenamente a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, além de que o “modus operandi” do casal criminoso, demonstra organização que merecia maior rigor punitivo; todavia, como não é possível “reformatio in pejus”, a pena cominada na r. sentença deve prevalecer – Preliminar rejeitada, recurso parcialmente provido. (Apelação Criminal n. 1.044.309-3/5 – São Paulo – 6ª Câmara Criminal – Relator: Marco Antonio – 23.8.2007 – V.U. – Voto n. 6.277)

Portanto, levando em conta o dado elencado, no aspecto acima relatado (quantidade da droga), elevo a pena-base em 1/6 (um sexto), resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes e atenuantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase, é de se reconhecer a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº. 11.343/06, porquanto a prova nos autos é segura o bastante para afirmar que a prática delitiva ocorreu entre os Estados do Mato Grosso do Sul e São Paulo. Logo, aumento a pena em mais 1/6 (um sexto), resultando em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Ainda na terceira fase, quanto ao artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, entendo não ser caso de sua incidência. Restou demonstrado, por todos os elementos acima descritos, bem como pela apreensão de grande quantidade de maconha, que a acusada se dedicava à narcotraficância em escala expressiva, de modo que é forçoso reconhecer que se dedicava a atividade criminosa, fazendo do tráfico o seu meio de vida.

Neste sentido, já se decidiu:

“Sem incidência, porém, na última fase da dosagem, de retroativa redutora, por conta do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, visto que, pese a primariedade e bons antecedentes, concretamente, a forma de embalagem da droga apreendida (cerca de sessenta e cinco invólucros), sua natureza (crack) e forma de ação desenvolvida – para fim de venda a indeterminado número de pessoas – antes de caracterizar eventual pequeno tráfico, traz indicações de fazer do fato modo de vida, exercício de atividade criminosa.”

Em outros termos, a quantidade expressiva de entorpecente, inversamente ao princípio da insignificância, poderia causar consequências gravíssimas a um número imenso de pessoas, bem como denota periculosidade acentuada por parte da acusada, já que realizava o tráfico em escala considerável, o que deve ser diferenciado do pequeno traficante, sob pena de violação do primado da igualdade, razão pela qual não faz “jus” a redução em questão.

Torno definitiva a pena em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Diante da gravidade da conduta, mesmo levando-se em conta a detração penal da Lei 12.736/12, a pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente em regime fechado, obrigatoriamente, conforme estatuído no art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464, de 28/03/2007.

Ademais, infere-se inviável, de igual sorte, a alteração do regime prisional, na hipótese, com esteio no lapso que perdurou a prisão cautelar, porque não se tem notícia a respeito da real situação carcerária da acusada, isto é, se não registra outras condenações ou prisões processuais, nem quanto ao seu comportamento e conduta no cárcere, a revelar não existirem elementos seguros para a correta análise, nesta seara e de pronto, quanto a eventual direito à detração penal, emergindo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, à míngua de informações concretas.

A acusada deverá continuar a responder presa por este processo, pois assim permaneceu durante a instrução e ainda estão presentes os requisitos da custódia cautelar, como se verá doravante.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica da ré.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR MARGARETH CAMPOS DOS SANTOS, qualificada nos autos, ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado (art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação da Lei nº 11.464/07), e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no menor valor (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06), dando-a como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso V, ambos da Lei nº. 11.343/06.

Consigno que a acusada está presa cautelarmente desde 02/04/2022 até a presente data, período sobre o qual fica reconhecida a detração penal, para fins de cumprimento do restante da pena, nos termos do que dispõe o artigo 1º da Lei nº

12.736/12.

Deve, no entanto, a Serventia, ao expedir a Carta de Guia, atentar para se consignar a condenação total constante do dispositivo acima, com as observações consignadas no parágrafo anterior (detracção penal).

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por entender incabível tal providência.

Não obstante o julgamento do Habeas Corpus n. 97.256, pelo Supremo Tribunal Federal, no qual se entendeu por inconstitucional a vedação à substituição por penas restritivas de direitos para o crime de tráfico, por afronta ao princípio da individualização da pena, até então não se trata de decisão proferida com efeito erga omnes.

Foi editada a Resolução nº 5/2012, do Senado Federal, que, nos termos do artigo 52, inciso X, da Constituição Federal, suspendeu a execução de parte do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, que vedava de forma abstrata (sem análise do caso concreto) a conversão em penas restritivas de direito, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo em decisão no Habeas Corpus já mencionado acima.

Com a mencionada Resolução, não se pode mais afirmar que o efeito do julgamento daquele habeas corpus não é para todos. Entretanto, a intenção do Supremo Tribunal Federal, ao decidir desta forma, e o Senado Federal, ao editar a resolução, foi somente deixar à prudente análise do magistrado do caso concreto se os réus têm ou não direito a ter a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, e não que essa substituição seja admitida em qualquer caso de tráfico de drogas, indistintamente. Pensar assim seria um contrassenso.

Confira, neste sentido, decisão proferida em Apelação Criminal que analisou sentença proferida por este juízo:

"... Inviável, nesse passo, a pretendida substituição carcerária por restritivas de direito, porque, embora o teor da recente Resolução nº. 5/2012 do Senado Federal, fundada na decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos do Habeas Corpus, nº. 97.256/RS - mencionado nas razões recursais -, em controle difuso de constitucionalidade, in casu, permanece impossível, data vênica, a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, ou mesmo a concessão de sursis, pois o crime de tráfico de entorpecentes revela a gravidade peculiar que desestabiliza a vida em sociedade e fere de morte a saúde pública, pois enquanto fomenta, simultânea e irremediavelmente - até as pedras estão cansadas de saber -, a violência, a destruição de lares e das famílias e a prática de n crimes, sobretudo para o fim de viabilizá-lo, tanto assim que, por força de norma constitucional, é assemelhado aos delitos hediondos, cuja pena deve ser cumprida no regime prisional inicial fechado, determinação esta que se mostra incompatível com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou com a suspensão condicional da pena, de modo que não se consegue compreender ou avaliar, por mais que se esforce, qual seria a pena substitutiva ou as condições do sursis adequadas ao traficante, emergindo sintomático que - até o momento - jurista sério algum tenha ousado sugerir-las..." (TJ-SP, Apelação Criminal nº 0009435-15.2010.8.26.0077, 5ª Câmara Criminal, rel. Des. Juvenal Duarte, j. 19.04.2012).

Ainda no mesmo sentido, confira julgamento proferido em processo que tramitou por essa comarca de Birigui:

"Também não faz jus a apelante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados a tráfico de drogas é incompatível com a gravidade e as circunstâncias em que o crime é cometido, não havendo qualquer tipo de violação ao princípio da individualização da pena.

Este entendimento deve prevalecer, notadamente ao se considerar a vedação expressa trazida pelo artigo 44 da Lei de Drogas.

Com efeito, o benefício consistente na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos tem por objetivo primordial o de possibilitar a

ressocialização de indivíduos de baixa periculosidade, que praticaram delitos de pequeno grau de lesividade social.

Traficantes de substâncias entorpecentes, sejam de pequeno, médio ou grande porte, não tem o perfil de iniciar o cumprimento de sua pena que não mediante encarceramento. Mesmo o pequeno traficante merece uma punição severa. Basta que a venda de drogas seja realizada uma única vez, para que cause uma série de malefícios ao consumidor, as quais virão a repercutir a toda a coletividade. Ressalta-se que uma das exigências previstas no artigo 44, inciso III, do Código Penal, para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é a de que os motivos e as circunstâncias indiquem como suficiente tal medida, para a repressão do agente da conduta delituosa.

Conforme já fundamentado, tal benefício não se coaduna com as graves consequências que a mercancia de substâncias entorpecentes causa, não só ao usuário, com uma rápida deterioração da sua saúde física e mental, mas também ao corpo social (desestrutura familiar, estímulo à prática de outros crimes, como homicídios, latrocínios, extorsões etc.).

Muito embora o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do "Habeas Corpus" nº 97256/RS, tenha expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida no § 4º, do artigo 33, da Lei 11343/06, é de se ressaltar que tal decisão não possui o erga omnis.

E mesmo a resolução nº 5 do Senado Federal, de 15 de fevereiro de 2012, que suspendeu a eficácia da referida expressão, não acarreta direito subjetivo do agente que praticou o grave delito do tráfico de entorpecentes a tal conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Frise-se, ainda, que o artigo 44 da Lei de Drogas mantém tal vedação ao crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput. Considerando que o § 4º é tão somente uma causa de diminuição do delito previsto no caput - e não um crime autônomo -, é possível concluir que a vedação a ele também se aplica.

Neste aspecto, ensina Guilherme de Souza Nucci que "(...) o fato de haver sido prevista uma causa de diminuição de pena para o traficante primário, de bons antecedentes, sem outras ligações criminosas, não afasta a tipificação da sua conduta como incursas no artigo 33, caput e § 1º, que são consideradas similares a infrações penais hediondas, como se pode observar pelas proibições enumeradas no artigo 44 da Lei 11343/06. Salienta-se, ademais, o cuidado legislativo em vedar a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, típica opção de política criminal para o tráfico ilícito de drogas. Não se pode criar uma nova infração penal, a partir da mera aplicação de causa de diminuição de pena. Por isso, o tráfico ilícito de drogas será sempre considerado equiparado a hediondo, ainda que comporte, por opção legislativa, pena mais branda, quando os requisitos do § 4º estiverem presentes" (in "Leis Penais e Processuais Penais Comentadas", 5ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2010, p.372).

Desta forma, NEGOU PROVIMENTO ao recurso, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau" (Apelação Criminal nº 0002364-20.2014.8.26.0077. Rel. Toloza Neto).

Não bastassem todos os argumentos expostos no voto supracitado, no caso concreto, a substituição não é possível, porque, além de a pena aplicada ser superior a quatro anos, o benefício não seria recomendável, nem suficiente para a prevenção e repressão do crime praticado, lembrando que a acusada transportava grande quantidade de entorpecentes (1.025,47 gramas de maconha), o qual seria levado do Estado do Mato Grosso do Sul para o Estado de Goiás.

A acusada deverá continuar a responder presa a este processo, pois foi presa em flagrante delito e sua prisão foi convertida em preventiva, conforme decisão proferida às fls. 36/37, cujos argumentos ficam aqui reiterados, como razão de decidir, assim como aqueles expostos à fls. 137/138 que indeferiu o pedido de liberdade provisória.

Ademais, continuam presentes os requisitos que recomendam a custódia cautelar da acusada, mormente porque praticou delito equiparado aos hediondos, demonstrando periculosidade em transportar grande quantidade de droga para consumo de terceiros,

entre Estados da Federação. Nesse aspecto, a ordem pública merece resguardo. Outrossim, seria uma verdadeira contradição que tivesse sido mantida presa durante toda a instrução e agora, condenada, viesse a recorrer em liberdade. Recomende-se a ré na prisão em que se encontra, com fundamento nos artigos 59 da Lei nº 11.343/06, c.c. o § 4º do artigo 2º da Lei nº 8.072/90, acrescentado pela Lei nº 11.464/07.

A incineração da droga já foi determinada (fls. 36/37) e realizada (fls. 106/107), nada mais havendo a ser decidido a respeito.

Quanto ao celular, bolsa e balança apreendidos a fl. 15, diante da natureza dos objetos e por se tratar de instrumentos do crime de tráfico, entendo não ser caso de perda, mas sim destruição, a qual fica desde já determinada, cujo cumprimento, no entanto, deverá ser levado a efeito somente após o trânsito em julgado da presente, expedindo-se o necessário e comunicando-se a Sala de Armas e Objetos Apreendidos.

Oficie-se à Delegacia de Polícia de origem, informando sobre a destruição dos objetos, instruindo-se o ofício com as cópias necessárias.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica da ré.

Com o trânsito em julgado da presente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, nos termos do artigo 28 da Resolução nº 23.399/13 do TSE, instruindo o ofício com cópias da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Custas, na forma da lei.

P. R. I.

Birigui, 01 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA